

1500497-77.2022.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... representam o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Eventualmente, pediu que seja afastada a causa de aumento estampada de forma inovadora nas alegações finais do Ministério Público, referente ao cometimento de crime pelo réu no interior de transporte coletivo. Defendeu que se trata de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, em razão das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

1500497-77.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 31/08/2022 10:11:08 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a) Juiz(a) de Direito desta Comarca, o(a) Exmo(a) Sr.(a) Dr.(a) Viviane Cristina Parizotto Ferreira, para deliberações. Eu, Wellington Rodrigo de Souza Bosso, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

1500497-77.2022.8.26.0483

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO MARCIO DE FARIAS PETRONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de FABIANO MÁRCIO DE FARIAS PETRONIO, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois no dia 19 de julho de 2022, por volta das 3h10min, na Rodovia SP 270 Km 616+500m, neste município, o réu transportava, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e um) "tijolos" e 01 (uma) embalagem pequena e transparente, ambos contendo a substância "maconha", totalizando o peso de 43,682 Kg da droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme faz certo o laudo pericial de fls. 86/88.

Narra a denúncia que durante procedimento de fiscalização na rodovia Raposo Tavares, policiais militares pararam um ônibus coletivo itinerário Ponta Porã/MS x

São Paulo, e ao abordarem o réu que se encontrava na poltrona 37, encontraram dentro de sua bolsa uma pequena porção de uma erva de cor esverdeada acondicionada num plástico branco. Na ocasião, durante o procedimento, indagaram se o pertencia, sendo a resposta negativa. Passaram a fiscalizar, junto ao controle de bagagens, e verificaram que o réu ainda tinha duas bolsas no bagageiro externo. Ao checarem, encontraram mais 51 “tijolos” do entorpecente. Foram apreendidos ainda, R\$ 387,00 em espécie, bem como um aparelho celular. É confidente quanto a porção encontrada dentro de sua mochila, porém desconhece a quem pertence as bagagens encontradas no bagageiro externo (fls. 6). Em razão da quantidade, espécie e forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como do numerário apreendido, conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico. Requeru seja reconhecida a perda em favor do Estado ou de entidade beneficente especializada no tratamento e recuperação de viciados, do numerário e objeto apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06 (fls. 11).

A denúncia (fls. 97/98) veio acompanhada do incluso inquérito policial (nº 68/2022), instaurado mediante flagrante (fls. 01/02).

Em audiência de custódia (fls. 60/64), foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva. Outrossim, foi autorizada a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do réu para que seja levado a exame pericial.

Mandado de prisão cumprido a fls. 70/72.

Folha de antecedentes e certidão de objeto e pé (fls. 56/57).

Laudo pericial de substância entorpecente (fls. 86/88).

Laudos realizados no aparelho celular e chip do réu (fls. 150/166).

O réu foi notificado (fls. 168) e apresentou defesa preliminar, por intermédio da qual a defesa requereu a rejeição da denúncia, em razão de nulidade e inépcia, bem como pugnou pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura (fls. 106/117), sobrevindo, após manifestação do Ministério Público (fls. 143/144), decisão de recebimento da denúncia em 11 de agosto de 2022, sendo certo que foram afastadas as preliminares arguidas e indeferido o pedido de liberdade provisória (fls. 169/174).

A defesa peticionou a fls. 200, requerendo a juntada de declarações abonatórias de terceiros em favor do réu (fls. 201/204).

Em sede de instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogou-se o réu na sequência, declarando-se encerrada a instrução. Outrossim, foi indeferido o pedido de liberdade provisória feito pelo defensor do réu (fls. 205/208).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Pediu o aumento da pena do réu na primeira fase, em razão da imensa quantidade de droga apreendida, bem como na terceira fase, em razão do tráfico praticado entre Estados da Federação e uma vez que o crime foi cometido no interior de transporte coletivo pelo réu (fls. 205).

Por fim, o acusado apresentou suas alegações finais, por meio das quais a defesa requereu a nulidade da busca pessoal, pois realizada apenas com base no suposto nervosismo do réu e, consequentemente, de todas as provas derivadas dela, requerendo seu desentranhamento do processo. Alegou que não há comprovação que o réu entrou com outras bolsas no ônibus, pois apenas entrou com sua mochila.

Sustentou que o réu teve um relacionamento com Bianca e que, em razão disso, traria de São Paulo objetos para ela revender em Natal-RN. Salientou que as fotografias do celular do réu não representam o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Eventualmente, pediu que seja afastada a causa de aumento estampada de forma inovadora nas alegações finais do Ministério Público, referente ao cometimento de crime pelo réu no interior de transporte coletivo. Defendeu que se trata de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, em razão das características do réu. Pediu que a pena base seja mantida no mínimo legal. Pediu, por fim, que o réu possa recorrer em liberdade (fls. 206).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De saída, passo à análise da alegação de nulidade das provas pela defesa em sede de

alegações finais.

Não se desconhece a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça preconizando que a mera delação anônima, o suposto nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial ou, ainda, a fuga diante da tentativa de abordagem, não autorizam a busca pessoal desprovida de ordem judicial. Entretanto, não há se cogitar da alegada nulidade decorrente da colheita da prova se as circunstâncias fáticas antecedentes dão suporte à averiguação, como no caso dos autos, revestindo-a de licitude. Nesse sentido:

"A disciplina legal a respeito da busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. A presença de elementos concretos, tangíveis e demonstráveis é exigida em razão da garantia constitucional de proteção à privacidade e à intimidade e justifica, ainda, a exigência de prévias e fundadas razões para mitigar a garantia de inviolabilidade domiciliar, também de índole constitucional. Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo. Neste caso, policiais deram ordem de parada ao paciente, que dispensou um pote branco que estava segurando e esboçou fuga, razão pela qual se pode aferir que o contexto fático antecedente autorizou a medida tomada pelos policiais." (STJ, HABEAS CORPUS Nº 723390/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática, DJe 11/05/2022).

No caso em tela, forçoso reconhecer, a partir do contexto delineado nos autos, a existência de fundadas razões para a realização da abordagem seguida de busca pessoal no réu, mormente porque, na data dos fatos, os policiais realizavam a Operação denominada Sufoco de fiscalização do tráfego da Rodovia SP 270 – Raposo Tavares, KM 616 + 500m, sendo certo que entrevistaram todas as pessoas que estavam no interior do ônibus e, quando abordaram o réu, este apresentou nervosismo e versões desconexas, o que motivou os policiais a fazerem a revista pessoal (fls. 03/05), tanto que foi localizada droga com o réu, o qual negou que a maconha lhe pertencia, bem como ainda negou que as bagagens localizadas com mais droga eram suas, em que pese estarem etiquetadas com o número da sua poltrona, tudo a indicar o cometimento do delito.

Acresça-se que a Polícia detém a incumbência de garantir a paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, agir de forma que impeça sua ocorrência ou, na hipótese de flagrante, lançar mão de meios que subsidiem a apuração do fato criminoso; o que significa, no caso concreto, estar ela investida legitimamente da autoridade para efetuar a abordagem de quem se suspeita estar em flagrante delito.

Vide, sobre o tema, as seguintes decisões do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituenta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituenta, podendo ser utilizada para justificar a

manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitativa. 4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 18/3/2022) – grifei.

"TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. 2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior. 3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente." (STJ, HC 552.395/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/03/2020) – grifei. Portanto, fica rechaçada a alegação de nulidade da busca pessoal do réu e demais provas dela derivadas, não havendo ainda que se falar em desentranhamento do processo.

De outro vértice, anoto que, com respeito à correlação entre a acusação e a sentença, a simples leitura da inicial acusatória assegura que na descrição fática do ilícito imputado ao acusado constou expressamente que durante procedimento de fiscalização na rodovia Raposo Tavares, policiais militares pararam um ônibus coletivo itinerário Ponta Porã/MS x São Paulo, e ao abordarem o indiciado que se encontrava na poltrona 37, encontraram dentro de sua bolsa uma pequena porção de uma erva de cor esverdeada acondicionada num plástico branco. Na ocasião, durante o procedimento, indagaram se pertencia ao réu, sendo a resposta negativa. Passaram a fiscalizar, junto ao controle de bagagens, e verificaram que o indiciado ainda tinha duas bolsas no bagageiro externo. Ao checarem, encontraram mais 51 "tijolos" do entorpecente. Foram apreendidos ainda, R\$ 387,00 em espécie, bem como um aparelho celular (fls. 97) – grifei.

Por isso, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, deve ser considerado na sentença o que dispõem os artigos 33, caput, e 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006.

Em outras palavras, a hipótese é de emendatio libelli, não de mutatio libelli (artigo 384 do estatuto processual penal). Ao tratar da emendatio libelli, estabelece o artigo 383 do Código de Processo Penal que "o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Depreende-se desse dispositivo legal que o réu defende-se da imputação fática contida na denúncia, não da classificação jurídica a ela dada pelo respectivo signatário. Nessa linha, aliás, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 56.874 in DJU de 8 de junho de 1979; RTJ 168/921 e 174/589), do Superior Tribunal de Justiça (RT 771/551) e do Tribunal de Justiça (JTJ 234/324).

Há, no mesmo sentido, diversos outros julgados: "o acusado se defende dos fatos imputados na peça acusatória e não do dispositivo legal citado." (Habeas Corpus nº 83.855-3/MG rel. Nelson Jobim). "Eventual erro na capitulação legal pode ser corrigido no momento da sentença, ex vi do art. 383 do CPP, sem causar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia. (precedentes)." (Habeas Corpus nº 17.197/PR rel. Felix Fischer). "A jurisprudência deste Tribunal é

tranquila quanto à possibilidade do juiz dar, na sentença, definição jurídica diversa da que consta na denúncia. Só não seria possível tal procedimento se, para caracterização do novo delito, faltasse alguma circunstância elementar que não estivesse descrita implícita ou explicitamente na denúncia" (Habeas Corpus nº 82.589-3/ BA rel. Nelson Jobim).

No mais, o presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), autos de exibição/apreensão e constatação (fls. 12/14), fotografias da referida droga (fls. 22/34) e laudos periciais (fls. 86/87 e 160/166).

Outrossim, a sua autoria se afigura inequívoca nos autos, não havendo dúvida, ainda, sobre a caracterização do tráfico de entorpecentes, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que o acusado foi preso em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Tanto em sede policial quanto em juízo, interrogado, o réu contou que estava no Município de Dourados-MS visitando a cidade, onde comprou uma passagem de ônibus da Viação Mota saindo de Dourados-MS com direção a Presidente Prudente-SP, por meio do aplicativo "Pegue Ônibus". Disse que quando chegasse em Presidente Prudente, compraria uma nova passagem de ônibus e seguiria para São Paulo. Relatou que embarcou no ônibus da Viação Mota carregando somente uma mochila e que dentro da mochila havia apenas roupas. Confirmou, no entanto, que também carregava uma porção de maconha dentro da mochila, sendo certo que comprou em Ponta Porã-MS, pelo valor de R\$ 20,00. Sobre as bagagens etiquetadas com a numeração de sua poltrona, sustentou desconhecer a quem pertencem tais bagagens. Com relação ao laudo pericial realizado em seu celular, alegou que as bagagens mencionadas nas conversas não se tratavam de drogas, mas de confecção, e quanto ao pó disse que se tratava de maconha ruim, cuja droga iria fumar. Disse que iria até São Paulo comprar duas malas grandes de confecção, depois pegaria um ônibus até o Nordeste. Aduziu que emprestou o celular para um rapaz conhecido de Bianca, a qual é ex-ficante do interrogando, com quem conversou sobre o transporte de roupas de São Paulo até Natal. Afirmou que os policiais não lhe mostraram os lacres das malas, bem como não mostraram o conteúdo e disseram que o interrogando era o portador, mas não encontraram com o mesmo nenhuma etiqueta vinculada ao embarque das bolsas, nem mesmo o motorista afirmou que as bolsas eram do interrogando. Afirmou que levou apenas sua mochila quando embarcou no ônibus. Disse que primo Paulo é quem lhe vendeu a droga em Ponta Porã, o qual estava na presença de Antonio. Salientou que tem residência fixa e trabalha como engenheiro (fls. 06 e 208).

Todavia, a negativa do réu não merece credibilidade, restando isolada no mosaico de provas.

Com efeito, a testemunha policial militar, Alexandre Castelani Cardoso, revelou que estava realizando a Operação denominada Sufoco de fiscalização do tráfego da Rodovia SP 270 - Raposo Tavares, KM 616 + 500m, sendo certo que abordou o ônibus da empresa da Viação Mota que faz itinerário interestadual Ponta Porã/São Paulo e durante a vistoria do ônibus, no salão interno de passageiros, se encontrava o réu sentado na poltrona de número 37. Narrou que com seu colega de equipe, Marcelo, entrevistaram Fabiano sobre os motivos de sua viagem e este apresentou nervosismo e versões desencontradas e desconexas. Em razão disso, o depoente e seu colega vistoriaram sua bagagem de mão e encontraram uma porção de substância que se assemelhava a maconha. Questionado a respeito, contou que o réu negou que a maconha lhe pertencia, disse que apenas fumava, mas que a substância pertencia ao seu primo Paulo. Disse que perguntou ao réu se havia mais bagagens e ele negou. Contou que

checou na listagem de bagagens que fica em poder do motorista e encontrou duas etiquetas de bagagens vinculadas à poltrona 37, motivo pelo qual desceu ao compartimento externo de bagagens e o motorista abriu o bagageiro. Informou que localizaram as duas bagagens com as etiquetas relacionadas à poltrona 37 e, em vistoria, encontraram dentro delas 51 tabletes de substância que se assemelhava a maconha. Salientou que, antes de vistoriar as bagagens, primeiro perguntou para o réu qual o número de sua poltrona e recebeu como resposta que ele se sentava na poltrona 37. Após a confirmação de o réu ocupava a poltrona 37 é que as bagagens foram abertas na sua presença. Diante desse cenário, relatou que o réu foi encaminhado para o Plantão de Polícia Judiciária para as devidas providências legais, sendo necessária o uso de algemas para preservação da integridade física da equipe policial e do conduzido e para evitar fuga, porquanto a viatura policial não possui compartimento de transporte de preso. Afirmou que tudo que presenciou, o seu colega Marcelo também presenciou. Disse que na data dos fatos, o que mais chamou atenção foi que a conversa do réu não tinha nexos, pois o mesmo portava seu documento e a passagem era eletrônica, dizendo que morava em Natal/RN e tinha ido para São Paulo/SP na casa de um primo e dali até Dourados/MS foi com o primo Paulo de automóvel, bem assim que de lá foi até Ponta Porã/MS comemorar o aniversário da cidade, e ainda disse que os amigos de seu primo Paulo que estavam com eles naquela oportunidade se chamavam Antonio e Carlos, depois disse que se chamavam João e Antonio, bem como não soube precisar o endereço do seu primo Paulo na cidade de São Paulo. Salientou que todas as bagagens de todos os passageiros foram revistadas no ônibus. Frisou que o réu estava nervoso no momento da entrevista. Não se recorda se havia alguém sentado ao lado do réu. Afirmou que todas as bagagens estavam etiquetadas e atreladas a passageiros e poltronas. Esclareceu que o réu presenciou a abertura das malas, que estavam etiquetadas com o número da poltrona dele. Por fim, asseverou que o réu não ofereceu resistência (fls. 05 e 207).

Saliento que a situação funcional dos agentes de polícia não os inibe de deporem, e nem uma espécie de suspeição genérica pode retirar-lhes toda e qualquer credibilidade. Importante, assim, é destacar a jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a respeito deste tema:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7), adotando o mesmo sentido TJSP: RT 433/386-7, RT 715/439; TJPR: RT 554/420 (TJSP – Apelação Criminal nº 278.743.3/5-Garça).

Relembro ainda que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

Além disso, nada há nos autos a revelar que os policiais teriam alguma razão para injustificadamente incriminar pessoas inocentes, não havendo razão para que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, fossem apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes.

Dessa forma, vê-se que testemunhas e policiais, via de regra, têm apenas o interesse de contar o que se deu efetivamente, o que coloca suas palavras em elevado grau de confiabilidade, autorizando o édito condenatório. Policiais são agentes credenciados pelo Estado e, como tais, suas palavras devem ser dignas de fé. Afinal, seria um verdadeiro contrassenso revesti-los dessa qualidade e, ainda assim, deles suspeitar. De há muito está superada a corrente jurisprudencial que questiona a presunção de veracidade pela natureza da função exercida.

Noutro giro, em análise ao laudo pericial acostado a fls. 150/166, que foi realizado no aparelho celular e no chip de propriedade do réu, verifico a existência de conversas por meio de aplicativos que indicam a prática do tráfico de drogas por parte do réu, tais como conversas com o contato "Bian", referindo-se a Bianca, onde nota-se alusão ao consumo e transporte de drogas, inclusive, quando o réu lhe informa que já está nas bolsas, aponta que não coube em uma bolsa só 43,5

kg, ou seja, exatamente a quantidade apreendida nas malas que estava etiquetadas com o número da poltrona do réu (fls. 160), tendo Bianca indagado ao réu onde ele ia deixar o pó, o qual lhe disse que teria que comprar duas malas para botar no porta malas do ônibus, devendo comportar 15 kg (fls. 161), além de várias fotografias e vídeos de drogas sendo pesadas e embaladas (fls. 162/165), o que denota seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas, a despeito de ser primário (fls. 56/57).

Ademais, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, ante os depoimentos serenos e uniformes dos policiais militares, em sede policial e em juízo; o nervosismo do réu e as versões desconexas ao ser entrevistado pelos policiais; a localização de drogas em sua mochila e nas malas que estavam no bagageiro do ônibus, devidamente etiquetadas com o número de sua poltrona; a quantidade da droga (43,682 quilogramas de maconha), devidamente acondicionadas em 51 tijolos, além de 01 embalagem pequena e transparente (típica forma de comercialização); além do laudo pericial realizado no celular do réu, que evidenciou a necessidade de compra das malas para transportar drogas, tendo o réu alegado que as malas não eram suas, sintomática da consciência da gravidade do ilícito penal, induzem à convicção de que este, sem sombra de dúvidas, praticava o delito de tráfico de drogas.

Anoto que as alegações apresentadas pelo réu em seu interrogatório, o que serviu de tese para sua defesa em sede de alegações finais, não restou comprovado nos autos, cabendo salientar que sequer foi arrolada qualquer testemunha para ratificar suas declarações em sede policial e em juízo, seja "Bianca", sua "ex-ficante", ou o "primo Paulo".

Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou alibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de droga encontrada, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

No caso em tela, como se verificou, o réu transportava 43,682 quilogramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha entre as cidades de Ponta Porã-MS e São Paulo-SP, sendo certo que foi preso em flagrante nesta cidade e Comarca, enquanto viajava em um ônibus da "Viação Motta", que trafegava na Rodovia Raposo Tavares.

Consigno, dessa forma, a incidência das causas de aumento de pena descritas no artigo 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, a caracterização de tráfico em transporte público e entre Estados da Federação.

Portanto, incabível no presente caso a causa de diminuição de pena mencionada no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, na medida em que, em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixou o réu, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, fatores já mencionados.

Colaciono aos autos, consoante entendimento do C. STF, que "a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010), sendo, portanto, descabido o redutor previsto no § 4º supracitado.

No mesmo sentido, as decisões de lavra do Eg. TJSP:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição -

Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusados surpreendidos enquanto transportavam, entre Estado da Federação, 25,5kg de maconha e 6.65kg de cocaína - Confissão parcial de um dos réus - Negativa do corréu isolada nos autos - Firmes e coerentes depoimentos dos policiais civis dando conta do envolvimento dos acusados na prática delitiva - Validade - Circunstâncias da apreensão evidenciam que ambos os agentes tinham conhecimento dos entorpecentes - Condenação de rigor. Associação para o tráfico - Expressiva quantidade de drogas aliada à existência de denúncias sobre a utilização do mesmo carro em outras oportunidades para transportá-las indicam a permanência e estabilidade da ação dos réus - Animus associativo caracterizado - Condenação mantida. Dosimetria das penas - Tráfico - Penas-base 1/3 acima do mínimo legal - Possibilidade - Quantidade e variedade de entorpecentes - Acréscimo em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 - Reconhecimento da confissão judicial em favor do réu Marciel - Incidência da Súmula 545 do C. STJ - Reprimendas elevadas em 1/6 pela regra do inc. V, do art. 40, da Lei 11.343/06 - Redutor do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 - Inaplicabilidade - Denúncias anônimas aliadas ao montante dos entorpecentes evidenciam que os réus se dedicavam a atividades criminosas - Associação par ao tráfico - Penas-base no mínimo legal, elevadas em 1/6 pela regra do inc. V, do art. 40, da Lei 11.343/06 - Delitos autônomos - Reprimendas somadas por força do concurso material - Substituição penal incompatível com o total das penas impostas - Regime inicial fechado - Manutenção - Penas excedentes a 08 anos de reclusão - Gravidade concreta dos fatos - Conduta que poderia vir a atingir inúmeros usuários - Tráfico de cocaína - Droga de alto poder lesivo à Saúde Pública - Necessidade de resposta estatal mais rigorosa na repressão do crime - Recurso do réu Marciel parcialmente provido - Recurso do corréu Eberson desprovido." (TJSP; Apelação 0000572-67.2018.8.26.0537; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018) - grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes e condutas afins - Absolvição por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, apontando para a ocorrência de erro de tipo - Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida - Não vislumbrada a presença de qualquer causa excludente da tipicidade - Redução das penas ao mínimo legal, afastando-se a causa de aumento disposta no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, bem como seja fixado regime prisional mais brando, operando-se, inclusive, a detração - Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, adequados ao caso concreto, salientada a presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido e os maus antecedentes do agente, a impedir inclusive a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas - Bem delineada a incidência da citada majorante, vez que o acusado transportava o entorpecente entre diferentes estados da Federação - Necessária a imposição de regime prisional contundente e eficaz à conscientização da ilicitude e prevenção da reincidência - Eventual pleito de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato - Pedido de apelo em liberdade já deferido anteriormente pelo d. juízo "a quo", determinada, contudo, a prisão do acusado, diante do presente julgamento - Apelo não provido." (TJSP; Apelação 0001508-66.2015.8.26.0515; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018) - grifei.

A condenação, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário e sem antecedentes criminais (fls. 56/57). Outrossim, há que se considerar a grande quantidade de droga apreendida (43,682 quilogramas de maconha), a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006: "Art. 42. O juiz, na

fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.". Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor unitário. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que não existem agravantes nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, como demonstrou a prova colhida nos autos, o tráfico de drogas se deu entre uma unidade da Federação para outra e por meio de transporte público, razão pela qual estão configuradas as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, III e V, da Lei nº 11.343/06, de sorte que majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), elevando-a ao patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Em relação à causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, por sua vez, tal como já fundamentado, é cediço que tal minorante visa conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim concebido o agente que, *ipsis litteris*, "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Em exegese ao referido dispositivo, a jurisprudência deflagrou o entendimento de que a quantidade e a diversidade da droga revelam-se, igualmente, como importantes vetores para a caracterização do pequeno traficante, sendo, portanto, passíveis de infirmar tal qualificação. Seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, em que apreendidos 43,682 quilogramas de maconha, corrobora-se a inaplicação desta causa excepcional de diminuição de pena.

Além disso, foi o acusado flagrado transportando grande quantidade de maconha, no interior de veículo de transporte rodoviário coletivo, entre Estados da Federação, o que denota, por si só, em razão do alto valor agregado, certo grau de envolvimento com organização criminosa, senão vejamos:

"APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas pela prova documental e oral – Pleito defensivo de mitigação da pena e ministerial de exasperação de reprimenda – Razão ao Ministério Público, somente – Confissão parcial que deve ser extirpada, pois não constitui atenuante – Afastamento da majorante consistente no transporte interestadual de drogas – Impossibilidade – Causa de aumento sobejamente demonstrada – Réu surpreendido em ônibus originário de Campo Grande/SP e com destino a Penápolis/SP – Conhecida rota de transporte de drogas – Decote da minorante prevista no art. 33, §4.º, da referida lei – Cabimento – Elementos que indicam envolvimento com a espúria engrenagem da narcotraficância – Regime inicial fechado único adequado – Impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e sursis, ante o quantum de pena: superior a 04 anos. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido." (TJSP; Apelação 0012845-80.2014.8.26.0032; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2015; Data de Registro: 18/08/2015) – grifei.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Cada dia-multa fica fixado no mínimo legal, ante a ausência de elementos seguros e concretos acerca da condição financeira do réu. Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque a pena aplicada supera o limite legal.

O regime inicial será, a teor do art. 2º, § 1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa, o fechado.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR FABIANO MÁRCIO DE FARIAS PETRONIO, RG: 2432261/PB, filho de Francisco Petronio e Selma de Farias Petronio, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal e atualizado monetariamente desde a época do fato.

O réu viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, de sorte que lhe nego o direito de recorrer em liberdade, considerando-se, ainda que, tratam os autos de crime que traz evidentes repercussões negativas à sociedade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Vencido, o réu arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, guardados os limites da Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 05 de setembro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA